

제55회 변리사 2차 시험 디자인보호법 답안 – 김월랑, 문희 변리사

【문제-1】(30점)

디자인 상호간의 권리관계에서, 후출원 등록디자인이 선출원 등록디자인을 그대로 이용하는 이용관계에 있는 경우에는, 후등록디자인의 임의적 실시는 선등록디자인권의 침해가 된다. 디자인의 선후관계와 이용관계에 대한 다음 설문에 답하시오.

(1) 이와 같은 디자인보호법 제95조에 의한 이용관계의 법적효과가 귀속되기 위한 광의의 요건을 총체적으로 설명하되, 디자인 상호간의 이용관계의 본질에 관한 학설과 협의의 디자인 이용관계의 성립요건에 관한 판례의 입장에 비중을 두고 설명하시오. (10점)

(2) 다음 1), 2)의 경우, 후출원이 디자인 등록 가능한지를 선원주의 관점에서만 판단하고, 양자가 모두 디자인 등록이 된다면 선후 등록디자인 상호간에 이용관계가 성립하는지를 판단하시오. (12점)

1) 선출원 디자인이 양념용기 세트 중 후추통 디자인이고, 후출원이 그 후추통을 포함한 한 벌의 양념용기세트 디자인인 경우 (5점)

2) 선출원 디자인이 형상만의 디자인이고, 후출원이 그 형상에 모양 및 색채를 부가한 결합디자인인 경우 (7점)

(3) 선등록디자인이 형상·모양이 결합된 벽지 디자인이고, 후등록디자인이 그 형태에 색채를 부가하고 일부 모양을 변형한 벽지 디자인인 경우에도 양자간 이용관계가 성립될 수 있는지를 논하시오. (8점)

I. 문제의 소재

II. 설문(1)의 해결 – 이용관계의 요건

1. 이용관계의 의의, 취지

2. 성립요건 – 출원일 상이/권리자 상이/적법하게 등록된 2이상 권리/이용하는 관계

3. 이용관계 개념에 관한 견해

(1) 문제점 간단히

- (2) 학설 – 주요부포함설/개량확장설/그대로설/실시불가피설
- (3) 판례 – 비유사, 요지 전부 포함, 본질 손상 X -> 그대로설의 입장
- (4) 검토 – 그대로설
- 4. 효과 – 적극적효력 제한, 소극적 효력 제한 X 간단히 기재

III. 설문(2)의 해결

- 1. 문제점 – 선출원주의(46조)
- 2. 설문 1)의 해결
 - (1) (등록가능 여부) – ①구성물품과 한벌물품간 유사판단 ②사안의 경우, 선원주의 위반 X
 - (2) (이용관계 성립 여부) – ①한벌물품디자인의 경우 ②사안의 경우, 이용관계 ○
- 3. 설문 2)의 해결
 - (1) (등록가능 여부) – ①형상만의 디자인의 유사판단 기재 ②선원주의 위반 X
 - (2) (이용관계 성립 여부)
 - 1) (학설) – 긍정설, 부정설, 구별가능성설, 절충설
 - 2) (판례) – 이용관계 판례/간단히
 - 3) (검토) – 이용관계 긍정 또는 부정으로 일관되게 기술.
 - 4) (사안의 경우) – 이용관계 긍정 또는 부정

IV. 설문(3)의 해결

- 1. 유사판단 - ①형상/모양 기본법리 ②모양의 판단기준 ③색채는 고려X
- 2. 이용관계의 성립 여부
 - (1) 색채는 고려 X
 - (2) 나뭇잎 판례
 - (3) 사안의 경우 – 본질적 특징의 손상 여부에 따라 이용관계 성립여부 달라질 수 있으나, 일반적으로 벽지는 모양의 비중이 크므로 이용관계 성립하지 않음.

대법원 2011. 4. 28. 선고 2009 후 2968 판결

[권리범위확인(디)][공 2011 상,1071]

【판시사항】

[1] ‘후 디자인이 선 등록디자인을 이용하는 관계’의 의미

[2] 확인대상디자인은 명칭이 “직물지”인 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자기의 디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없어 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없음에도, 이와 달리 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례

【판결요지】

[1] 선 등록디자인과 후 디자인이 이용관계에 있는 경우에는 후 디자인은 선 등록디자인의 권리범위에 속하게 되는바, 후 디자인이 선 등록디자인을 이용하는 관계란 후 디자인이 전체로서는 타인의 선 등록디자인과 유사하지 않지만, 선 등록디자인의 요지를 전부 포함하고 선 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자신의 디자인 내에 도입하고 있어, 후 디자인을 실시하면 필연적으로 선 등록디자인을 실시하는 관계에 있는 경우를 말한다.



[2] 확인대상디자인 “ ”은 명칭이 “직물지”인 등록디자인

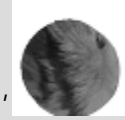


“ ”의 ‘V’자 모양과 유사한 모양이 일부 반복하여 이루어지다가 그 사이 사이에 큰 **나뭇잎** 모양이 위와 아래로 서로 엇갈리게 반복하여 이루어진 것이 혼연일체로 결합하여 하나의 디자인을 형성하고 있어서 등록디자인의 본질적 특징인 위 ‘V’자 모양이 상하좌우로 연속적으로 반복된 부분 중 상당한 부분이 손상되어 있으므로, 확인대상디자인은 등록디자인의 본질적 특징을 손상시키지 않은 채 그대로 자기의 디자인 내에 도입하고 있다고 할 수 없어 등록디자인을 이용하는 관계에 있다고 할 수 없음에도, 이와 달리 본 원심판결에 디자인의 이용관계에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 않은 위법이 있다고 한 사례.

【문제-2】(20점)



甲은 토끼의 귀와 꼬리에 착안한 디자인 ' '을 창작하여 물품(휴대폰 케이스)



의 본체부분을 제외한 상부(귀)인 ' '와 하부 돌출 부분(꼬리)인 ' '만을 보호받고자 부분디자인으로서 도시하여 하나의 디자인등록출원을 하였으며, 디자인의 설명란에 "1. 토끼의 귀 모양에는 이어폰의 와이어를 감을 수 있고 꼬리부분은 휴대폰을 경사지게 지지하는 것임, 2. 본 물품의 도면 중 회색으로 표현된 케이스 본체의 점선부분을 제외한 나머지 부분을 부분디자인으로서 디자인등록을 받고자 하는 부분임"이라고 기재한 디자인등록출원서 및 도면을 제출하였다.

(1) 甲의 출원이 부분디자인으로서 1디자인의 단일성 요건(디자인보호법 제40조 제1항의 '1디자인')을 충족하는지 여부를 형태적 일체성과 기능적 일체성의 견지에서 논하시오. (10점)

(2) 甲의 출원이 등록된 경우, 1) 제3자의 무단실시에 따른 부분디자인권의 보호범위(유사판단) 판단과 2) 제3자의 후출원에 관한 등록요건(신규성, 선원주의, 확대된 선원)을 판단함에 있어, 부분디자인을 특정하면서 도시한 파선부분(회색 본체부분)을 어떻게 취급하여야 하는지에 대하여 각각 논하시오. (10점)

I. 문제의 소재

II. 부분디자인(2조1호괄호)

1. 의의, 취지, 위반시 취급
2. 사안의 경우 - 성립요건 바로 포섭

III. 설문(1)의 해결 - 1디자인1출원주의(40조1항)

1. 의의, 취지

2. 1디자인마다의 출원

- (1) 1디자인의 의미
- (2) 1 물품의 성립
- (3) 1 형태의 성립 – 창작의 일체성
- (4) (부분디자인의 경우) – 형태적 일체성/기능적 일체성 심사기준 기재

3. 설문의 해결

- (1) (대법원 판례)
- (2) (사안의 해결) – 단일성 요건 충족

IV. 설문(2)의 해결 – 부분디자인의 보호범위 및 파선부분의 취급

1. 보호범위(92조)

- (1) (일반) 물품의 동일/유사를 전제로 그 부분의 형태와 동일/유사한 형태를 포함하는 전체디자인의 실시에도 미침
- (2) 학설- 요부설/독립설, 우리나라는 요부설
- (3) 유사판단 심사기준 – 2018 개정 내용 포함 (파선에 차이가 극히 미세한 경우, 양 디자인 동일하다는 내용 포함)
- (4) 검토 – 파선부분 고려해서 유사판단 수행하는 것이 타당.

2. 심사자료로서의 취급

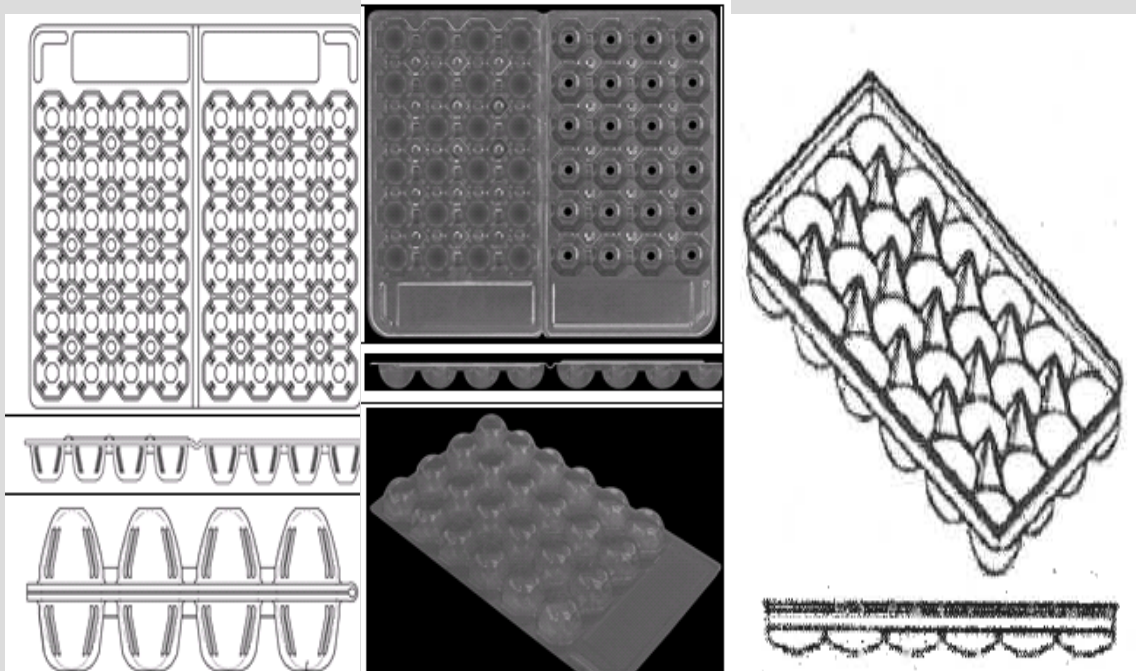
- (1) 신규성 – 도면 공지시 전체
- (2) 선원주의 – 실선
- (3) 확선주의 – 대비가능 할 정도로 충분히 표현된 경우 파선도 지위 가짐.

3. 결어 – 전체디자인은 부분의 실시배제효를 갖지 못하므로, 부분디자인권도 취득하는 것이 실효적 보호 측면에서 타당.

【문제-3】(30점)

甲은 '메추리알 포장용기'디자인 A에 대하여 2014년 디자인등록을 하였다. 乙 또한 자신의 '메추리알 포장용기'디자인 B에 대하여 2015년 2월에 출원하여 동년 12월 디자인등록을 마쳤다. 2016년 甲은 특허심판원에 등록디자인 B가 자신의 등록디자인 A와 유사하여 신규성이 없다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 받아들여지지 않았다.

한편 사건 외 丙은 '메추리알 포장용 상자'디자인 C에 대하여 甲, 乙보다 먼저 디자인등록을 한 바 있으나 이미 존속기간이 만료된 상태이다. 디자인 C의 난좌(卵座)부분(반구형태)은 '메추리알 포장용기'관련업계에서는 주지된 일반적 형상으로 알려져 있다.



(1) 甲은 특허법원에 심결취소소송을 제기하여 승소하였으나, 대법원이 이를 파기환성하자, 甲은 환송 후 특허법원의 심결취소소송 절차에서 소외 丙의 디자인 C를 제시하며 등록디자인 B가 디자인보호법 제33조제2항 '공지디자인과 주지형태의 결합에 기초한 용이 창작 디자인임'을 주장하고 있다. 甲의 주장 및 증거의 절차적 적법성 여부에 대하여 논하시오. (8점)

(2) 상기 (1)에서 甲의 주장과 증거가 채택되었음을 전제로, 등록디자인 B의 창작비용이성 해당여부의 판단기준을 설명하고, 우리 법원의 입장에서 최종판단하시오. (12점)

(3) 한편 등록디자인 B의 무효 확정 전에, 乙은 丁이 실시하고 있는 '메추리알 포장용기'디자인 B에 대하여 적극적 권리범위확인심판을 청구한 바 있다. 만약 丁이 실시하고 있는 디자인 D가 디자인 C로부터 용이하게 창작할 수 있는 것이라면, 乙의 심판청구에 대하여

丁은 어떠한 항변이 가능한지 논하시오. (10점)

I. 문제의 소재

II. 설문(1)의 해결

1. 심결취소소송에 대하여

(1) 의의, 취지

(2) 심리범위

1) 학설 – 제한설/무제한설

2) 판례 – 특허법 판례 기재,

3) 검토 – 당사자계이므로 무제한설 타당

2. 설문의 해결 – 주장 및 증거 적법

III. 설문(2)의 해결

1. 문제점

2. 창작비용이성(33조2항) – 단문

(1)(의의, 취지)

(2)(개정법) 14년 7월 1일 개정법

(3)(판단기준)

(4)(판단방법)

(5)(위반시 취급) – 거/정/무

3. 설문의 해결

(1) 메추리알 판례 – 창작성 X

(2) 사안의 경우 - 창작성 X이므로, 인용판결 내려질 것이다.

IV. 설문(3)의 해결

1. 문제점 - 92조, 침해요건(유[공정력]/정/보/업/실)

2. 적극적권리범위확인심판(122조)에 대하여

(1) 의의, 취지

(2) 적법성 심리 - 판례는 디자인권 소멸후 청구의 이익이 없다고 하였으나, 무효 확정 전이므로 청구 이익이 인정됨, 이해관계인 맞음 (간단히)

(3) 본안 심리

1) 자유실시디자인의 항변 - ①(판례) 창작성 관련 최신판례 기재 ②검토 ③사안 - 가능

2) 무효의 항변 - ①(판례) 창작성 위반의 무효의 항변 불가 ②검토 ③사안 - 불가

3) 권리남용의 항변 - ①특허판례 및 검토 간단히 ②사안 - 불가

4) 비유사의 항변 - 간단히

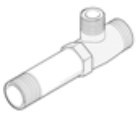
3. 설문의 해결 - 자유실시디자인의 항변에 의하여, 기각심결 예상됨.(다만, 심결시 전 디자인 B 무효 확정시 청구이익없어 각하심결 가능성 有)

대법원 2016. 8. 29. 선고 2016 후 878 판결

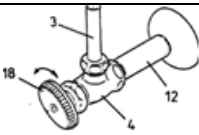
[권리범위확인(디)][공 2016 하,1555]

【판시사항】

[1] **등록디자인과 대비**되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 경우, 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부(소극)

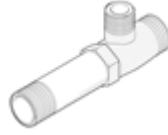
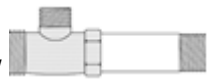
[2] 물품의 명칭이 “밸브 하우스”인 등록디자인 “  , ”  ”의

디자인권자 갑 등이 을을 상대로 확인대상디자인 “  ”과 등록디자인이 특징적인 부분들이 서로 동일하거나 유사하여 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원이 심판청구를 인용하는 심결을 한 사안에서, 확인대상디자인이 통상의

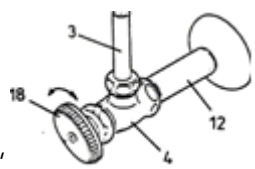
디자이너가 비교대상디자인 “”, “”에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 디자인이라고 한 사례

【판결요지】

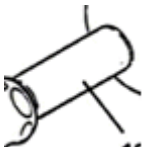
[1] **등록디자인과 대비**되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 **등록디자인과 대비**할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

[2] 물품의 명칭이 “밸브 하우징”인 등록디자인 “”, “”의

디자인권자 갑 등이 을을 상대로 확인대상디자인 “”과 등록디자인이 특징적인 부분들이 서로 동일하거나 유사하여 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데, 특허심판원이 심판청구를 인용하는 심결을 한 사안에서,

확인대상디자인과 비교대상디자인 “”, “”을 **대비**하여 보면

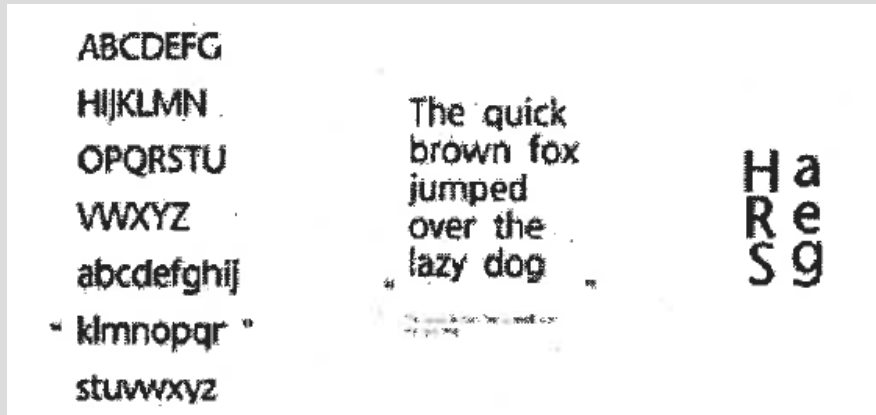
양 디자인은 모두 본체(“”, “”), 배출구(“”,

“”), 조임볼트(“”, “”), 공급관(“”, “”)의

연결구조가 전체적으로 “”와 같은 형상과 모양을 이루는 점 등에서 공통되어 주된 창작적 모티브를 같이 함을 알 수 있으므로, 확인대상디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 디자인임에도 이와 달리 본원심판결에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.

【문제-4】(20점)

甲회사는 자사 홍보를 목적으로 다음과 같은 글자체를 개발하고 디자인등록출원을 하였다.



(1) 甲회사의 글자체가 디자인보호법상 보호대상인 글자체 디자인이 되기 위한 성립요건을 설명하시오. (6점)

(2) 甲회사의 글자체 디자인의 등록요건에 대한 심사 시, 글자체 디자인 상호간의 유사판단기준에 관하여 설명하시오. (7점)

(3) 甲회사의 글자체 디자인이 등록된 후, 인쇄소를 운영하는 乙은 시중에 유통 중인 甲의 등록 글자체 디자인을 이용하여 청첩장을 제작하였다. 乙의 행위가 甲의 디자인권 침해를 구성하는지 여부를 논하시오. (7점)

I. 문제의 소재

II. 설문 (1)의 해결 - 글자체디자인

1. 의의, 취지
2. 성립요건
3. 위반시 취급
4. 설문의 해결 - 기공한모시 만족하여 글자체디자인이다.

III. 설문 (2)의 해결

1. 유사판단 일반 법리

2. 글자체 디자인의 경우

(1) 글자체간 물품 비유사

(2) 심사기준 - 복기부자

(3) (판례) 글자체 특성 고려

3. 소결 - 기본형태와 가독성 고려해서 판단.

IV. 설문 (3)의 해결

1. 문제점 - 침해/ 유정보업실

2. 글자체디자인의 효력 및 효력제한

(1) 92 조

(2) 효력제한(94 조 2 항)

3. 설문의 해결 - 침해판단

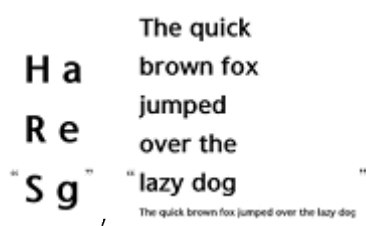
통상적 과정에서 사용하는 경우로 침해아님

대법원 2012. 6. 14. 선고 2012 후 597 판결

[거절결정(디)][공 2012 하,1237]

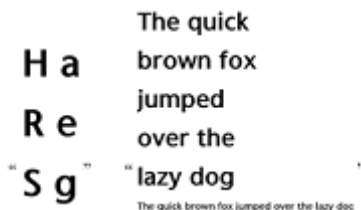
【판시사항】

[1] 디자인보호법 제 2 조 제 1 호의 2에서 정한 **글자체** 디자인의 유사 여부 판단 기준

[2] 출원디자인 ,  과 비교대상디자인  은 전체적으로 볼 때 유사한 디자인에 해당한다고 본 원심판단이 정당하다고 한 사례

【판결요지】

[1] 디자인의 등록요건을 판단할 때 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 다른 심미감을 느끼게 하는지에 따라 판단해야 하므로, 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 이러한 법리는 [디자인보호법 제 2 조 제 1 호의 2](#)에서 정한 **글자체**에 대한 디자인의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 한편 **글자체** 디자인은 물품성을 요구하지 않고, 인류가 문자생활을 영위한 이래 다수의 **글자체**가 다양하게 개발되어 왔고 문자의 기본형태와 가독성을 필수적인 요소로 고려하여 디자인하여야 하는 관계상 구조적으로 디자인을 크게 변화시키기 어려운 특성이 있으므로, 이와 같은 **글자체** 디자인의 고유한 특성을 충분히 참작하여 유사 여부를 판단하여야 한다.

[2] 갑이 출원디자인  을 출원하였으나 특허청이 출원 전에

인터넷에 공지된 비교대상디자인  과 유사하다는 이유로 [디자인보호법 제 5 조 제 1 항 제 3 호](#)에 따라 등록거절결정을 한 사안에서, 두 디자인은 모두 고딕체로서 선의 굵기가 세로에 비해 가로가 약간 가늘고, 대문자와 소문자인 'H, R, S, a, e'는 각 가운데를 경계로 상하로 동일한 분배와 무게중심을 가지며, 글자의 너비와 곡선 기울기, 형태 등이 유사한 점 등에서 지배적인 특징이 유사하고, 다만 소문자 'g'의 경우 출원디자인은 , 비교대상디자인은  와 같아서 원형 부분과 아래의 꼬리 획 부분의 공간을 차지하는 비중이 약간의 차이가 있고 전체적으로 출원디자인이 비교대상디자인보다 글자가 굵게 표현된 차이는 있으나 심미감의 차이를 유발할 정도는 아니라는 이유로, 두 디자인은 전체적으로 볼 때 유사한 디자인에 해당한다고 본 원심판단이 정당하다고 한 사례.

55기 변리사 시험을 준비하시느라 너무 고생하셨으며, 모두 좋은 결과 있으시길 바랍니다.